

1500286-56.2020.8.26.0145

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Comarca: Conchas

Foro: Foro de Conchas

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... prestação de que tinha, mas não oriundo do tráfico; no local não foi encontrado nenhum objeto que tivesse relação com o tráfico; nada relacionado com o tráfico foi encontrado no local; tinha a testemunha João, que foi conduzido à delegacia e discriminou que ele e o Lucas iriam fazer uso ("dar um tiro"), e foram impedidos no momento que chegaram; e foram apreendidos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchas

Foro de Conchas

2ª Vara

Rua Goiás, 521, Conchas-SP - cep 18570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500286-56.2020.8.26.0145 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500286-56.2020.8.26.0145

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2192209/2020 - DEL.POL.CONCHAS, 8447124 - DEL.POL.CONCHAS, 272/20/206 -

DEL.POL.CONCHAS, 2192209 - DEL.POL.CONCHAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS CRISTIANO DE ALMEIDA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de LUCAS CRISTIANO DE ALMEIDA e ADÃO FELIPE PIRES DA SILVA. Narra a denúncia que, no dia 04 de agosto de 2020, por volta das 15h30min, na Rua Sargento Afonso de Simone Neto, nº 114, neste município e comarca de Conchas, LUCAS CRISTIANO DE ALMEIDA e ADÃO FELIPE PIRES DA SILVA, qualificados, respectivamente às fls. 8 e 9, durante estado de calamidade pública, mantinham em depósito, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 08 (oito) porções de cocaína, com peso aproximado de 28 gramas (vinte e oito gramas), conforme auto de exibição e apreensão às fls. 06 e laudo toxicológico definitivo às fls. 29/32. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, LUCAS e ADÃO mantinham em depósito as referidas drogas com o fim específico de entrega para o consumo de terceiros.

A denúncia foi recebida a fls. 124/125 (01 de agosto de 2021).

Citados, os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 161/162).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, após, os réus foram interrogados.

As partes apresentaram memoriais a fls. 225/228 e 232/240.

É o relato. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Lucas Cristiano de Almeida e Adão Felipe Pires da Silva, imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c arts. 29 e 61, inciso II, alínea 'j', do CP.

A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos seguintes elementos: laudo definitivo (fls. 29-32); laudos em aparelhos celulares (fls. 98-104 e 105-111) e depoimentos colhidos em audiência de instrução, inclusive a confissão do réu. Com efeito, o laudo definitivo indicou a existência de invólucro com massa líquida de 25,06 gramas, a qual apontou a existência de cocaína.

Referida substância é considerada droga, nos termos do previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.343/2006, o qual estabelece considerar-se como tal “as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União”. A lista mencionada foi indicada nos laudos periciais logo após a identificação de cada uma das porções.

Além disso, no laudo de fls. 105-111, há troca de mensagens em que se verifica que uma pessoa pergunta a Adão se “tava vendendo drogas” (fl. 106), e este responde que sim, e questionado “KDE aquele menino honesto trabalhador?” (fl. 106), respondeu que as coisas mudam.

No que tange à caracterização do tráfico, vê-se que pela forma em que acondicionadas as substâncias, além de sua quantidade (considerável em termos de gramas líquidas), estavam separadas para venda e posterior consumo, situação inclusive corroborada pela troca de mensagens retirada do aparelho celular. De outro turno, os depoimentos fazem concluir no mesmo sentido.

Ouvido em juízo, José Sílvio Tomazella aduziu que na ocasião receberam na delegacia um disque denúncia, dando conta de que na borracharia o Lucas e o Adão estavam traficando cocaína; o depoente e o Luciano foram verificar a denúncia e chegando lá encontraram o Lucas com um amigo dele (acredita que João Luís); foi abordado o Lucas e com ele foram encontradas duas porções e R\$ 866,00; verificando uma escrivania que tinha lá encontraram mais quatro porções; ele admitiu que junto com o Adão haviam adquirido para consumo próprio; falou que o Adão tinha ido em uma auto-elétrica; em seguida foram atrás e encontraram outras duas porções e mais R\$ 260,00; o parceiro falou que o Lucas iria usar a droga com o colega; disse que iriam fornecer gratuitamente, assim para outros amigos, como já fizeram; falaram que no passado já haviam feito a traficância, mas atualmente só estavam como usuários e apenas forneciam aos amigos para uso em conjunto; os celulares foram apreendidos, porém nenhum outro objeto; e nenhuma outra droga foi encontrada. Já Luciano Del Bem afirmou que na ocasião a equipe da Civil de Conchas estava munido de disk denúncias de que na borracharia anexa ao auto-posto casarão estaria ocorrendo o tráfico e o consumo de drogas, realizados pelos réus; compareceram ao estabelecimento e no local estava apenas o Lucas; foi exposto o teor do disk denúncia ao Lucas e dada revista geral; foram localizados R\$ 870,00, que disse ser procedente do trabalho; na gaveta de uma escrivania foram localizadas duas porções de entorpecente e mais quatro porções no interior de uma mochila, que o Lucas falou pertencer a ele; indagado sobre o sócio na borracharia, ele indicou que o Adão estaria em uma outra oficina da cidade; foram até o local, o Adão foi abordado e foram encontradas 2 porções semelhantes à do Lucas; questionados, falaram que são usuários e compraram em parceria para fazer o consumo na borracharia, até para fazer uso com amigos em certas ocasiões; falaram que compraram em Laranjal Paulista; o dinheiro ele falou que era de uma prestação de que tinha, mas não oriundo do tráfico; no local não foi encontrado nenhum objeto que tivesse relação com o tráfico; nada relacionado com o tráfico foi encontrado no local; tinha a testemunha João, que foi conduzido à delegacia e discriminou que ele e o Lucas iriam fazer uso (“dar um tiro”), e foram impedidos no momento que chegaram; e foram apreendidos celulares.

Em seu interrogatório, Adão Felipe Pires da Silva disse que a acusação de tráfico não é verdadeira; foi na oficina; os policiais chegaram e pegaram as drogas;

pegaram as drogas e não chegaram a usar, junto com o Lucas; foi só para uso; pegavam a droga em Laranjal; juntamente com o Lucas geralmente, ou então um ia e trazia para outro; não fazia a venda, mas entregava para outros conhecidos; se chegasse um amigo, faziam o uso juntos; o dinheiro tinha pego da borracharia para pagar uma parcela do celular; o dinheiro era da borracharia mesmo; as mensagens no celular foi apenas uma brincadeira, porque estava interessado nela; e foi uma brincadeira na hora errada e no local errado.

Interrogado, o réu Lucas Cristiano de Almeida salientou que a acusação não é verdadeira; estava na borracharia trabalhando; foram denunciados; chegaram os policiais e como eram usuários pegaram os dois com uma porção que usavam; tinha um amigo que estava lá e iam usar naquela hora; estava em cima da mesa para o uso; tinha mais uma quantidade na mochila; adquiriu a droga em Laranjal Paulista; quando ia, ia sozinho e pegava também para o Adão, e este também, ou iam dois; o valor que tinha eram de pneus vendidos; foram vendidos 4 (quatro) naqueles dias, mais outros pneus meia vida; não tem conhecimento do Adão com tráfico; não tinha conhecimento de conversa dele com outras pessoas, narradas no celular; e quando faziam a aquisição em Laranjal, entregavam também para amigos, mas só aqueles que sabiam que gostavam, aí usavam juntos.

No que tange às teses defensivas (tanto a técnica quanto a pessoal), cabe destacar que para configuração do tráfico de entorpecentes é desnecessária a intenção de lucro, sendo que as condutas descritas pelos próprios acusados se amoldam ao art. 33 da Lei de Drogas.

Os acusados, ao assim agir, incidiu no disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o qual classifica como crime "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", devendo incidir nas penas a ele cominadas. Além disso, não há qualquer dúvida sobre a imputabilidade dos demandados em relação a tais fatos, o que sequer chegou a ser ventilado na hipótese.

2.2 A dosimetria da pena

2.2.1 O réu Adão Felipe Pires da Silva

No que tange à dosimetria da pena, em relação ao réu Adão Felipe Pires da Silva, destaco, na primeira fase (pena-base), que, de acordo com o art. 59 do CP: a culpabilidade (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie; não há maus antecedentes a serem considerados; inexistem informações suficientes acerca da conduta social (meio como se comporta no seio da sociedade) ou da personalidade (características pessoais advindas de sua psique); os motivos (as razões de sua prática), as circunstâncias (modo em que ocorreu) e as consequências (situações advindas da prática) também não se apresentam destoantes do que normalmente se espera nesses casos; e não há vítima direta por se tratar de delito vago.

Valora-se negativamente, entretanto, a natureza e a quantidade das drogas, na medida em que, a despeito da pouca quantidade em porções, a massa líquida da cocaína correspondeu a 25,06 g (vinte e cinco vírgula zero seis gramas), percentual significativo de droga sabidamente nociva.

Saliento, por oportuno, que: "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula n. 444 do STJ); e "a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial" (Súmula n. 241 do STJ).

Assim, majoro a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase (pena-provisória), destaco a inexistência de agravantes. Não reconheço a agravante de crime praticado em estado de calamidade pública (em razão da pandemia de COVID-19), porquanto referido estado não teve relação direta com a prática do fato (no mesmo sentido, desta Corte: TJSP; Apelação Criminal 1520980-88.2020.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 06/04/2021).

Todavia, presente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual retorno a pena para o mínimo legal.

Saliento que: "a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ), o que, por consequência, também inviabiliza sua majoração além do máximo; nos termos do já destacado acima, "a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial" (Súmula n. 241 do STJ); e "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal" (Súmula n. 545 do STJ).

Na terceira fase (pena-definitiva), destaco a inexistência de causas de aumento e a ocorrência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. Com efeito, o réu é primário e de bons antecedentes, além disso não há qualquer indício de que integre organização criminosa ou de que se dedique à atividade criminosa. Assim, porquanto da situação dos autos verifica-se que as partes faziam o tráfico em dupla, o que, apesar de não afastar a minorante, deve ser considerado pelo juízo, minoro a pena em 1/3 (um terço), e fixo como pena definitiva o montante de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Quanto à detração (art. 387, § 2º, do CPP), entendo que é matéria afeta à execução penal (art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal). Ademais, não houve prisão preventiva na hipótese.

Estabeleço: como regime inicial, o aberto, em razão do montante da pena e da inexistência de reincidência (art. 33, § 2º, 'c', do CP); e o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (art. 49, § 1º, do CP), notadamente por não haver outros elementos que possam indicar em sentido contrário.

No ponto, cabe destacar que: "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito" (Súmula n. 440 do STJ); "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Súmula n. 719 do STF); e "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou superior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (Súmula n. 269 do STJ).

Realizo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), porquanto: a pena aplicada não é superior a 4 (quatro) anos e o crime doloso não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente em crime doloso; e as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente (na medida em que foram em sua maioria neutras).

Vale destacar que: se a condenação é igual ou inferior a um ano, pode haver substituição por multa ou por uma pena restritiva de direitos; e, se superior, por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP).

Assim, a substituição, na hipótese deverá ocorrer nos seguintes termos: prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do CP); e limitação de fim de semana, para o fim de que permaneça, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, a ser indicado na posterior fase de execução, pelo período de duração da sanção corporal convertida (art. 48 do CP).

Destaco que entendo aplicáveis tais penalidades porque condizentes com os objetivos de ressocialização e responsabilização da pena, na medida em que a parte terá de prestar serviços à sociedade, a qual é a maior atingida com o tráfico de drogas, e terá limitados seus finais de semana. Ademais, salvo melhor juízo, seria ineficiente condenar ao pagamento de valores, porquanto o tráfico é praticado justamente em busca de dinheiro.

2.2.2 O réu Lucas Cristiano de Almeida

No que tange à dosimetria da pena, em relação ao réu Lucas Cristiano de Almeida,

destaco, na primeira fase (pena-base), que, de acordo com o art. 59 do CP: a culpabilidade (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie; não há maus antecedentes a serem considerados; inexiste informações suficientes acerca da conduta social (meio como se comporta no seio da sociedade) ou da personalidade (características pessoais advindas de sua psique); os motivos (as razões de sua prática), as circunstâncias (modo em que ocorreu) e as consequências (situações advindas da prática) também não se apresentam destoantes do que normalmente se espera nesses casos; e não há vítima direta por se tratar de delito vago.

Valora-se negativamente, entretanto, a natureza e a quantidade das drogas, na medida em que, a despeito da pouca quantidade em porções, a massa líquida da cocaína correspondeu a 25,06 g (vinte e cinco vírgula zero seis gramas), percentual significativo de droga sabidamente nociva.

Saliento, por oportuno, que: “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula n. 444 do STJ); e “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula n. 241 do STJ).

Assim, majoro a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase (pena-provisória), destaco a inexistência de agravantes.

Não reconheço a agravante de crime praticado em estado de calamidade pública (em razão da pandemia de COVID-19), porquanto referido estado não teve relação direta com a prática do fato (no mesmo sentido, desta Corte: TJSP; Apelação Criminal 1520980-88.2020.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 06/04/2021).

Saliento que: “a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula n. 231 do STJ), o que, por consequência, também inviabiliza sua majoração além do máximo; nos termos do já destacado acima, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula n. 241 do STJ); e “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal” (Súmula n. 545 do STJ).

Presente a atenuante da confissão. Diante disso, devolvo a pena ao mínimo legal. Na terceira fase (pena-definitiva), destaco a inexistência de causas de aumento e a ocorrência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. Com efeito, o réu é primário e de bons antecedentes, além disso não há qualquer indício de que integre organização criminosa ou de que se dedique à atividade criminosa. Assim, porquanto da situação dos autos verifica-se que as partes faziam o tráfico em dupla, o que, apesar de não afastar a minorante, deve ser considerado pelo juízo, minoro a pena em 1/3 (um terço), e fixo como pena definitiva o montante de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Quanto à detração (art. 387, § 2º, do CPP), entendo que é matéria afeta à execução penal (art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal). Ademais, não houve prisão preventiva na hipótese.

Estabeleço: como regime inicial, o aberto, em razão do montante da pena e da inexistência de reincidência (art. 33, § 2º, 'c', do CP); e o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (art. 49, § 1º, do CP), notadamente por não haver outros elementos que possam indicar em sentido contrário.

No ponto, cabe destacar que: “fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito” (Súmula n. 440 do STJ); “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula n. 719 do STF); e “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou superior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” (Súmula n. 269 do STJ).

Realizo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), porquanto: a pena aplicada não é superior a 4 (quatro) anos e o crime doloso não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente em crime doloso; e as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente (na medida em que foram em sua maioria neutras). Vale destacar que: se a condenação é igual ou inferior a um ano, pode haver substituição por multa ou por uma pena restritiva de direitos; e se superior, por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP).

Assim, a substituição, na hipótese deverá ocorrer nos seguintes termos: prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do CP); e limitação de fim de semana, para o fim de que permaneça, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, a ser indicado na posterior fase de execução, pelo período de duração da sanção corporal convertida (art. 48 do CP).

Destaco que entendo aplicáveis tais penalidades porque condizentes com os objetivos de ressocialização e responsabilização da pena, na medida em que a parte terá de prestar serviços à sociedade, a qual é a maior atingida com o tráfico de drogas, e terá limitados seus finais de semana. Ademais, salvo melhor juízo, seria ineficiente condenar ao pagamento de valores, porquanto o tráfico é praticado justamente em busca de dinheiro.

2.3 A indenização mínima

Deixo de fixar indenização mínima para a hipótese vertente, porquanto não houve pedido expresso nesse sentido na denúncia, o que impede sua concessão, conforme entendimento da Corte de Cidadania (AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018).

2.4 A prisão preventiva

Os réus poderão apelar em liberdade, porquanto foram condenados ao regime aberto e com substituição da reprimenda privativa de liberdade por restrição de direitos.

3 Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 387, do Código de Processo Penal condeno os réus Lucas Cristiano de Almeida e Adão Felipe Pires da Silva pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, para cada, substituídas por prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução, e limitação de fim de semana, para o fim de que permaneçam, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, a ser indicado na posterior fase de execução, pelo período de duração da sanção corporal convertida, nos termos da fundamentação supra.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais. Contudo, a respectiva exigibilidade está suspensa, durante o prazo extintivo de 5 (cinco) anos, em face da presunção de hipossuficiência financeira, consoante arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC.

Os réus poderão apelar em liberdade, conforme fundamentação acima. Expeça-se os respectivos alvarás de soltura.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União (art. 91, II, alínea 'a', do CP) e determino a destruição de eventuais drogas ainda guardadas referentes à infração (art. 71 da Lei n. 11.343/2006).

Fixo a remuneração do advogado dativo no máximo previsto na tabela da DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado: [a] comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da CF; [b] formem-se os autos de execução; e [c] proceda-se às demais determinações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpridas todas as determinações, arquivem-se.

Conchas, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA